

1500127-84.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... trazer consigo e guardar para fins de tráfico.

Vejamos o que há nos autos.

Os acusados, na fase policial, preferiram o silêncio.

Em juízo Gabriel confessou. Disse que estava traficando. Estava com toda a droga.

Wallace não estava envolvido com o tráfico. Recebe as drogas de pessoas de moto.

Era o primeiro dia no tráfico. Iria ganhar R\$ 500,00. Revolveu traficar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500127-84.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500127-84.2022.8.26.0617 - Controle nº 2022/000063

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL CAUAN DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

WALLACE CESAR DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA e GABRIEL CAUAN DA SILVA, já qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nos delitos capitulados nos artigos 33 "caput" e 35 "caput", todos da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 22h45, na rua Maria Martins Ottoboni, altura do nº 26, Campo dos Alemães, nesta, traziam consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Na mesma oportunidade e em datas anteriores, se associaram para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Policiais Militares avistaram o acusado Gabriel quando realizava a venda de entorpecente a usuário. Ao avistar a viatura tentou fuga. Foi perseguido e detido. Em uma sacola que o acusado carregava foram localizadas drogas de espécie diversas. Indagado, confessou a autoria do tráfico, afirmando que o dinheiro da venda estava com o acusado Wallace. Os policiais, então, realizaram a abordagem de Wallace, o qual estava na posse do dinheiro auferido com a venda do entorpecente.

Houve oferta de defesa preliminar.

Recebida a denúncia os acusados foram interrogados, não sem antes serem ouvidas as

testemunhas.

Em alegações finais o Ministério Público protestou pela procedência da ação, porquanto provadas autoria e materialidade.

A defesa de Gabriel disse que confessou. Não há prova estivesse associado. Caso condenado a pena deverá ser a mínima. Tem direito ao redutor. Tem direito ao regime aberto e à substituição. Deve apelar em liberdade.

A defesa de Wallace disse que não existem provas, por isso deve ser absolvido. Relatei.

Decido.

A ação procede parcialmente.

Como é cediço, para que se faça possível a decisão condenatória dois requisitos se mostram absolutamente necessários, sem os quais se impõe a absolvição.

Primeiro deve estar provada a materialidade, que, in casu, qualquer dúvida resta, ante a análise dos autos de constatação, exibição, apreensão e laudo toxicológico. Resta o segundo – autoria – ter a real certeza de que o sujeito ativo praticou o fato descrito na norma penal incriminadora.

Neste ponto, também nenhuma dúvida há eis que está sobejamente comprovado nos autos que ambos os acusados praticaram o fato descrito na norma penal inserta no art. 33 da Lei 11.343/06, na sua forma trazer consigo e guardar para fins de tráfico.

Vejamos o que há nos autos.

Os acusados, na fase policial, preferiram o silêncio.

Em juízo Gabriel confessou. Disse que estava traficando. Estava com toda a droga. Wallace não estava envolvido com o tráfico. Recebe as drogas de pessoas de moto. Era o primeiro dia no tráfico. Iria ganhar R\$ 500,00. Revolveu traficar por um "pensamento ruim". Está arrependido.

Wallace negou. afirmou que não estava traficando e sequer estaria sentado próximo ao local da abordagem de Gabriel.

A prova produzida nos autos condena apenas Gabriel.

Vejamos.

Dois policiais foram ouvidos. Em ambas oportunidades mantiveram a mesma versão acerca dos fatos. Disseram que patrulhavam pelo local dos fatos quando visualizaram o acusado Gabriel realizando a venda de droga a usuário. Resolveram pela abordagem. O acusado Gabriel tentou fuga, mas acabou detido. Com o acusado, em uma sacola plástica, os policiais localizaram 39 porções de maconha, 18 pedras de crack e 54 porções de cocaína, prontas para venda. Indagado, confessou a autoria do tráfico. Disse que o dinheiro era recolhido pelo acusado. Wallace. Que Wallace estava em uma bicicleta de frente ao local dos fatos. Que Wallace tentou fuga, mas foi perseguido e detido. Em revista pessoal localizaram o valor de R\$ 50,00, sendo uma nota de 20 reais e três notas de 10 reais. Wallace negou estivesse envolvido, disse que o dinheiro lhe pertencia. Acabaram presos.

Gabriel confessou.

Os policiais, um deles ouvido apenas na fase policial, confirmaram o tráfico.

Contaram sobre a apreensão do entorpecente e o ato de troca.

Não fosse isso, é cediço que em casos de tráfico, a substância entorpecente, no mais das vezes, está embalada de forma individual para facilitar o comércio a terceiros. O mesmo caminho trilha a jurisprudência:

"Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - rel. ENÉAS MACHADO COTTA, RDTJRJ 23/288).

"Identificando o fornecedor das substâncias tóxicas, em poder de quem foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, parte já dividida em dezenas de papelotes, prontos para entrega a consumo, impõe-se a condenação por tráfico, sem que se possa, todavia, reconhecer associação com compradores" (TJRJ - rel. PAULO GOMES DA SILVA FILHO, RDTJRJ 20/313).

Tudo o que está nos autos prova, sem sombra de dúvidas, o envolvimento do acusado Gabriel com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Resta agora analisar a situação de Wallace.

Narra a exordial que policiais militares lograram surpreender o acusado com R\$

50,00. Foi abordado porque o comparsa o teria delatado.

Em juízo, o acusado Gabriel assumiu ser o responsável pela droga e isentou Wallace de culpa.

O acusado, desde o início, negou tivesse ciência do tráfico perpetrado por seu namorado Laelson.

Não fosse a dúvida que já se mostra instalada, inclusive porque nenhuma das testemunhas viu o acusado na posse de qualquer entorpecente, as palavras do próprios corréu demonstra que ele não estaria envolvido com o tráfico.

Ou seja, não restou provado o auxílio, necessário a ver-se reconhecida a coautoria. Dispõe o art. 29 do Código Penal: "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

Quatro são os requisitos: 1) pluralidade de comportamentos, onde no mínimo duas pessoas realizam o próprio fato típico ou contribuem de algum modo para que outrem realize; 2) nexos de causalidade, a ação do autor ou partícipe deve ser relevante ou eficaz para o resultado; 3) vínculo subjetivo, sendo necessário que cada concorrente tenha consciência de contribuir para a atividade delituosa; 4) identidade de crime, objetiva e subjetiva para todos os concorrentes.

Em verdade, quaisquer dos requisitos acima declinados restaram comprovados, em especial o segundo, concernente na participação relevante e eficaz para o resultado.

O simples fato de estar no local não basta à configuração do concurso, pois sua conduta em nada inovou ou auxiliou no resultado.

Por isso, merece o acusado Wallace a absolvição.

Em razão da absolvição de Wallace, por óbvio não se sustenta o crime de associação para o tráfico.

Passo à dosimetria da pena.

O acusado é tecnicamente primário.

No mais, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis.

Estabeleço a pena base, no mínimo em 05 (cinco) anos de reclusão, além da pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa calculada na proporção mínima cominada em lei para o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Preso na posse de razoável quantidade de entorpecente, sem comprovar ocupação lícita, havendo confessado estar na atividade do vil comércio e, porque, posto em liberdade voltou a ser preso mais uma vez acusado de estar envolvido com o tráfico, nota-se que fazem do crime meio de vida, daí porque não faz jus à atenuante prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Não porque assim dispõe o citado dispositivo:

"Parágrafo quarto - Nos delitos definidos no caput e no parágrafo primeiro deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." (negritei)

Neste sentido restou decidido em recurso de apelação nº 0035632-25.2011.8.26.0577, oriundo desta Vara, cujo Relator foi Desembargador Geraldo Wohlers.

"Ressalte-se que a diminuição hoje admitida pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, não se mostrava viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade dos agentes.

O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda.

Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas".

Sabe-se que em termos repressivos o intuito constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide

sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico.

A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33.

Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.

É assim que se deve considerar a exigência de "não se dedicar às atividades criminosas" (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente.

Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante).

No caso concreto apurou-se que o acusado estava desempregado e, não obstante, detinha considerável quantidade de cocaína e de crack para expor à venda em local conhecido como pólo de mercancia, inferindo-se do entrelaçamento desses dados que, quando de sua prisão, o réu estava a exercer a mercancia ilícita como meio de vida - o que desautorizava, sem dúvida, a causa de diminuição colimada."

Nos termos do que dispõe a Lei 8.072/90, com redação alterada pela Lei nº 11.464, de 28.03.2007 (DOU 29.03.2007), bem como que o sentenciado se encontrava "batendo ponto" numa biqueira, trabalhando para o vil comércio e na posse de boa quantidade de entorpecente, o regime inicial somente pode ser o fechado.

E por que é assim?

É assim porque o tráfico de entorpecentes fomenta outros crimes. Infiltra-se na sociedade e é praticado, inclusive, dentro dos presídios.

Não se trata mais de crime que no passado era praticado de forma individual.

Atualmente, tanto o pequeno traficante, quanto o grande, fazem parte de um grande organismo, uma verdadeira indústria, e a retirada dos traficantes das ruas é um dos meios de combate ao crescimento desta indústria.

Por isso, buscando principalmente a manutenção da ordem pública, o único regime possível é o fechado.

Tudo o que foi exposto, somado ao fato de que Gabriel foi posto em liberdade e depois preso novamente, havendo descumprido as condições a eles impostas, processado e agora condenado, entendendo presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, notadamente no que concerne à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não resta outra decisão possível senão negar o apelo livre ao acusado Gabriel.

Anoto que é impossível a substituição ou o sursis diante da pena fixada.

Diante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

CONDENAR, GABRIEL CAUAN DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33 "caput" da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual na proporção mínima cominada em lei;

ABSOLVER, WALLACE CESAR DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA, já qualificado nos autos, da

acusação que lhe pesa como incurso nos artigos 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

ABSOLVER, GABRIEL CAUAN DA SILVA, já qualificado nos autos, da acusação que lhe pesa como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Nego o apelo em liberdade ao acusado Gabriel.

Recomende-se.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido, já que comprovada sua origem ilícita. Em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, EXTINGO as medidas cautelares impostas a(o)(s) ré(u)(s), apensando-se aos autos físicos do Inquérito Policial, se o caso e ainda em Cartório. Caso contrário, digitalizem-se as peças produzidas e as encarte na pasta digital, encaminhando-se em seguida para incineração.

Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoal, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s) para pagamento das custas e taxas processuais e, em relação à multa penal, com cobrança e, se necessário, execução, proceda-se nos termos do Provimento CG nº 5/22 (verificação de fiança recolhida nos autos, atualização, compensação/ abatimento ou extração de certidão de sentença ao MP); oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos, cumprindo-se, ainda, o determinado na sentença com relação ao perdimento de bens/valores apreendidos, com comunicação à SENAD nos termos do Comunicado CG nº 280/19, DJe de 06.03.2019.

Transitada em julgado, lancem-lhes os nomes no rol dos culpados.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

P.I.C.

São José dos Campos, 11 de julho de 2022.

CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA